

1501076-67.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501076-67.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271054/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 20648355 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2271054 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO JÚNIOR foi denunciado como incurso nas sanções do artigo

33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque no dia 04 de outubro de 2021, na rua Sebastião Cícero Franco, nº 33, Parque Brasil, nesta cidade e Comarca, nas proximidades de um estabelecimento de saúde, guardava, para consumo de terceiros, 07 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 3.450 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 222/235. Recebida a denúncia aos 30 de novembro de 2021 (fl. 252), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação (fls. 343 e 438) e uma da defesa (fl. 438). Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 533).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 537/543).

A defesa postulou a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fls. 551/557).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/120) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração argumentando que apenas parte da droga apreendida era de sua propriedade (200 gramas de maconha), pois destinada ao seu consumo pessoal.

Quanto ao restante do entorpecente (3 quilos de maconha), Demerval arguiu que não lhe pertencia e que sequer teriam sido localizados em sua casa.

Lado outro, não há dúvidas sobre a apreensão do entorpecente pelos policiais militares, especialmente porque o acusado não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse contaminar a diligência que culminou com a apreensão. Não é crível que agentes públicos inventem fatos ou “enxertem” a droga em desfavor de acusados, em especial quando nenhum vestígio a respeito existe nos autos.

No mais, ele se escusou da imputação através de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais lhe imputar injustificadamente tal crime.

Se não bastasse a força de convencimento ínsita nos argumentos expostos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O PM José Rodrigo esclareceu que naquela ocasião recebeu informação, via Copom, de que um determinado veículo estaria envolvido em crimes de estelionato e tráfico. Atento sobre a situação, durante patrulhamento de rotina naquele dia visualizou o veículo transitando pela Rodovia Capitão Bardoíno, razão pela qual decidiu abordá-lo.

Realizada contato, verificou que o acusado era condutor do veículo e tinha como passageira sua namorada Mirella. Posteriormente, revistou o veículo e observou que havia alguns resquícios de maconha em seu interior, além de uma quantia em dinheiro. Logo depois, o acusado admitiu aos policiais que guardava droga em sua casa, destinada ao comércio ilícito. Diante disso, se dirigiram até a sua residência, lugar onde foram encontrados três tijolos de maconha.

Eis suas palavras:

D: Excelência, a gente estava em patrulhamento pela avenida dos Imigrantes, esse veículo foi irradiado pelo COPOM da Polícia Militar, como estelionato e estava com queixa de tráfico. Ele estava descendo da Rodovia Capitão Bardoíno. Nós conseguimos abordar ele em local seguro, que foi na avenida Imigrantes, próximo ao

supermercado. E nesse meio termo, diversas viaturas também encostou no nosso apoio, nosso Sargento, nosso Tenente, e viaturas de força tática. Nós conseguimos abordar, estava ele com a namorada dele. Eu fiz a busca veicular, realmente estava com um forte indício de maconha, resquício no veículo, e uma quantia em dinheiro. Já o senhor Dermeval, quem fez a revista pessoal nele e a entrevista, foi o nosso comandante, e ele informou para o nosso Comandante, que na casa dele havia mais drogas, havia mais da substância que, diz ele, que estava comercializando. E nessa entrevista ele informou o nome de um traficante da região, forte daqui, o apelido dele é TG. Eu não sei o nome correto dele, excelência. E o Dermeval, segundo consta, ele faz parte de uma facção, o vulgo dele é China. Então, diante desses fatos, ele autorizou, nós fomos até a residência do mesmo. Eu fiquei na guarda dele né, do senhor Dermeval, e os policiais, o Cabo Andrade e o parceiro, junto com o nosso Comandante, fizeram toda a busca na residência e foi localizado sim. Se eu não me engano, foram três tijolos de maconha na residência do senhor Dermeval. Aí diante desses fatos, nós conduzimos ele até a delegacia.

Suas palavras são ratificadas pelo PM Bruno, que de forma séria e coerente descreveu a suspeita que levou os policiais a abordar o acusado e certificou o encontro das drogas em sua residência, a par de sua admissão informal sobre a existência das drogas em sua casa.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frisa-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a abordagem ao acusado e a revista pessoal, bem como o encontro das drogas em sua casa, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo correto. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014)

As testemunhas de defesa ouvidas não foram capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

Adjaelson não presenciou os fatos, apenas trazendo relatos sobre o proprietário anterior do veículo apreendido em poder na ocasião.

Por sua vez, Mirella disse que se encontrava na companhia do acusado quando foram abordados pelos policiais militares. Mencionou que somente na delegacia de polícia soube da apreensão das drogas e que tem conhecimento que o acusado é usuário de maconha.

Pontue-se, que as palavras de Mirella devem ser aceitas com ressalva. Isso porque ela é companheira do acusado, razão pela qual nítido é o seu interesse em protegê-lo. Ademais, ela não acompanhou a apreensão das drogas na casa de Demerval.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, a forma como estava acondicionada em sua forma bruta, pronta para ser fracionada, o local e as circunstâncias como foi surpreendido, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

A delação também deve ser levada em consideração porque jamais os policiais encontrariam a droga e investigariam a situação de traficância se não possuíssem informação confiável.

As denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas as delações com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afinal, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "guardar", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Ele não ostenta antecedentes criminais e os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade da droga apreendida, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 47), suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar ($7 \text{ anos} + 1/6 = 8 \text{ anos e } 02 \text{ meses} / 700 \text{ dias} + 1/6 = 816 \text{ dias-multa}$).

Na etapa derradeira, não deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III.

O laudo anexo (fls. 118/120) apontou que o lugar do crime dista cerca de 166 metros de um estabelecimento de saúde. A lei não especificou distância para aplicação da majorante, trazendo expressão que depende de interpretação, qual seja, nas imediações de....

A distância referida não pode ser considerada compatível com o termo imediações, que tem significado de redondezas, arredores, vizinhanças ou proximidades. Isto porque se exige uma caminhada para alcançar tal distância, além de estar comprometido o contato visual de qualquer pessoa normal, na maioria dos casos, como na espécie.

A par disto, a prova dos autos não demonstrou uma efetiva influência do tráfico exercido pelo agente neste local.

Logo, a proteção legal visando coibir o tráfico próximo à instituição em debate não deve operar na espécie.

O acusado é reincidente, razão pela qual não se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Acrescente-se, também, que a par da reincidência do agente, recentemente ele foi condenado por sentença não transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33, da lei de drogas (fls. 103 - sentença proferida aos 07/02/2020, reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Bragança Paulista -Processo nº 1500676-24.2019.8.26.0545).

Destarte, não obstante não seja possível sopesar tal registro para considerar o acusado reincidente ou portador de maus antecedentes, conforme entendimento reiterado do STJ, ele pode ser utilizado para afastar o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos previstos no § 4º, qual seja, não se dedicar às atividades criminosas.

Nesse sentido, segue-se orientação do STJ:

"Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas". (HC 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)." (HC nº 291.415/SP -)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.461 - MG (2018/0020255-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO

SALDANHA PALHEIRO RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECORRIDO : ALLAN PEREIRA SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS DECISÃO: (...) Além disso, nesta Superior Casa de Justiça, por ocasião do

julgamento do EREsp n. 1.431.091, ficou assentado ser "possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". A propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVALORAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, é necessário o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciado na conclusão de que o réu dedicava-se a atividades criminosas (traficância), ante a quantidade de drogas apreendidas (74kg de maconha), elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1.699.672/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018, grifei) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. 2. Não há constrangimento ilegal no ponto em que, fundamentadamente, não foi aplicada a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, à vista de elemento concreto que evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa do tráfico, consubstanciado na expressiva quantidade de droga apreendida (48 porções embaladas em plástico, 3 bastões tipo bananinha e 2 tijolos, com peso total de 185,02 g de maconha). [...] 4. Ordem não conhecida. (HC 293.802/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 29/10/2015, grifei) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EXISTÊNCIA DE FEITOS CRIMINAIS EM CURSO. CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, NA GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Consoante entendimento perfilhado pela Sexta Turma Corte nos autos do HC n.º 358.417/RS, "fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas". Do mesmo modo, nos autos do EResp n.º 1.431.091/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção consolidou o referido entendimento. Dessa forma, não há falar em ilegalidade, na espécie, tendo em vista que a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 foi negada por entender a Corte de origem que o paciente era renitente em atividades criminosas, porquanto já condenado anteriormente pela prática do mesmo delito. Ressalva do entendimento da Relatora. [...] 6. Habeas corpus parcialmente concedido a fim de fixar o regime inicial semiaberto. (HC 416.587/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017, grifei) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, AFASTADA EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça entende que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...] 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.136.353/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017, grifei) Assim, o acórdão local deve ser revisto para se adequar à jurisprudência desta Corte. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau (e-STJ fls. 266/278). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2018. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - RESp: 1721461 MG 2018/0020255-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 05/04/2018).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.328.077 - BA (2018/0171293-1) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO : BARBARA PATRICIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMPOS ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE MATOS MOTA E OUTRO (S) - BA034758 GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES - BA033560

DECISÃO: Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta o afastamento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que a existência de registros de outros processos criminais em desfavor da ré permite concluir pela dedicação da agente à prática de atividades criminosas. A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Por oportuno, segue a ementa do referido julgado: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 'assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito'. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017) Nessa linha, os seguintes precedentes desta Corte Superior: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4.º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIAS EM CURSO PODEM SER UTILIZADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PROVA DA MENORIDADE DOS SUPOSTOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. IDONEIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 453.370/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018). (STJ - AREsp: 1328077 BA 2018/0171293-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 04/09/2018).

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros

outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitativa, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Saliente-se, ainda, que mesmo diante da atual circunstância, a par da recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que sugere a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus, ela não o vincula, assim como não justifica por si só o pedido da defesa para conceder ao acusado o direito de apelar em liberdade com consequente liberdade provisória.

Deve se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas unidades prisionais, como a suspensão de visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc. ; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública segundo registrado reiteradamente na imprensa.

Infelizmente, todos os cidadãos do mundo estão expostos ao problema.

No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"...Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante

circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco..." (STJ AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

E mais:

HABEAS CORPUS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO REGIME E À PENA FIXADOS NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora - PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2055190-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e uso de distintivo ou uniforme de função pública que não exerce - Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação do direito de recorrer em liberdade - Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal - Decisão fundamentada relativamente à dosimetria penal e quanto à manutenção dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Periculum libertatis que não se mitiga, por si só, pela eclosão da pandemia de Covid-19 - Ausência de demonstração, ademais, da existência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento excepcional da postulação - Precedentes - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2081034-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

ENTORPECENTES.TRÁFICO (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Questões que devem ser discutidas no recurso de apelação já interposto pela Defesa. Deferimento ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento da responsabilidade de ambos por delito grave. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula nº 09, do C. Superior Tribunal de Justiça. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2091866-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR DEMERVAL NOVELLI ARAÚJO JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data,

face sua situação econômica.

Recomende-se na prisão onde ele estiver.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos com a promoção do crime, em virtude dos fundamentos utilizados nesta decisão, a teor do artigo 62, da Lei 11.343/2006. Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena, bem como adote-se o necessário para remessa ao Senad.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 06 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA